

1502423-23.2021.8.26.0453

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... até então não apreendida, cujo tráfico será apurado em separado). RAFAEL e FELIPE, interrogados, confessaram a prática delitiva (fls. 34/35 e fls. 21, respectivamente). ARTUR, por sua vez, não foi localizado para ser ouvido (fls. 174/178). Os objetos apreendidos foram avaliados em R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)".

A denúncia foi recebida em 28/10/2021 (fl. 207).

Os réus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí - Foro de Pirajuí - 2ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí-SP - cep 16600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo 1502423-23.2021.8.26.0453 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502423-23.2021.8.26.0453

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2291414/2021 - DEL.POL.PIRAJUI, 416/2021 - DEL.POL.PIRAJUI, 417/2021 - DEL.POL.PIRAJUI, 2291414 - DEL.POL.PIRAJUI, 416/21/111 - DEL.POL.PIRAJUI, 417/21/111 - DEL.POL.PIRAJUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SOARES DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. RAFAEL MORITA KAYO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por presentante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia RAFAEL SOARES DE SOUZA e ARTUR SOARES DE OLIVEIRA NETO, como incursos na prática do delito tipificado no art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal e FELIPE PEREIRA DA SILVA, como incurso no delito previsto no artigo 180 do Código Penal, conforme acusação inicial de fls. 185/187.

Narra a acusação, que, no dia 16 de outubro de 2021, durante a madrugada, na Rua Higino Marangon, 203, centro, nesta urbe e Comarca, Rafael e Artur, mediante prévio ajuste e com unidade de desígnios, durante o repouso noturno, subtraíram mediante escalada e para proveito comum, coisas alheias móveis tais como um televisor Smart full HD, 40 polegadas, de cor preta e detalhes cromados da marca LG, um botijão de gás, 1 lençol de cor rosa, diversas roupas, toalhas de banho e produtos de limpeza

pertencentes À vítima Juliana Aparecida Moraes de Souza, avaliados em R\$ 950,00. Após a subtração dos objetos, Felipe adquiriu em proveito próprio o referido televisor, coisa que sabia ser produto de crime.

Assim a denúncia descreveu as circunstâncias fáticas: "Segundo o apurado, na data dos fatos, os investigados RAFAEL e ARTUR dirigiram-se até a residência da vítima e, mediante escalada de um dos muros da residência, ganharam acesso ao quintal do imóvel da vítima. Ato contínuo, procederam à subtração dos objetos já mencionados, e evadiram-se do local, sendo que ARTUR, tomou rumo ignorado. Logo após a subtração, RAFAEL ofereceu o televisor para FELIPE, que adquiriu referido objeto que sabia ser produto de furto, em troca de 13 (treze) pedras de crack (droga até então não apreendida, cujo tráfico será apurado em separado). RAFAEL e FELIPE, interrogados, confessaram a prática delitiva (fls. 34/35 e fls. 21, respectivamente). ARTUR, por sua vez, não foi localizado para ser ouvido (fls. 174/178). Os objetos apreendidos foram avaliados em R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)".

A denúncia foi recebida em 28/10/2021 (fl. 207).

Os réus foram citados (fls. 292/293 e 398/399).

Ofertadas respostas à acusação (fl. 327 e 406).

Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal (fls. 410/411), foi designada audiência de instrução e julgamento nesta comarca.

O D. Promotor de Justiça ofertou em favor do réu Felipe o benefício da suspensão condicional do processo (fls. 464), considerando a sua primariedade.

Em audiência, foi concedido ao acusado Felipe o benefício da suspensão condicional (fls. 480/482), sendo que o feito foi desmembrado em relação a ele (fls. 496), gerando o feito 0000091-26.2022.8.26.0453 (fls. 504/507).

Na audiência de instrução e julgamento (fls. 516/518), foi coletada prova oral, ouvindo-se a vítima, testemunhas e interrogando-se os acusados. Ao final da audiência, a defesa de Artur pugnou pela liberdade provisória e a defesa de Rafael pleiteou a instauração de exame de averiguação de dependência toxicológica.

Por decisão de fls. 520/521, foi deferida a instauração de exame de dependência toxicológica em face de Rafael e concedido ao réu Artur o benefício da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

Instaurado incidente para averiguação de dependência toxicológica em face de Rafael, autuado sob n. 0000191-78.2022.8.26.0453.

Alvará de soltura cumprido em favor de Artur aos 04/02/2022 (fls. 531/534).

Autoridades policiais informaram descumprimento das medidas cautelares por parte do acusado Artur (fls. 541/551 e 554/567), o que ensejou no pedido de revogação da liberdade provisória concedida (fls. 568) e em novo decreto de prisão preventiva (fls. 570/571). O acusado Artur foi novamente preso aos 23/02/2022 (fls. 581/582).

Por decisão de fls. 635, foi determinado o desmembramento do feito em face de Artur, o que deu ensejo ao feito 0001785-30.2022.8.26.0453 (fls. 637/641). Diante disto, o presente feito tramita apenas em relação ao réu Rafael.

No incidente 0000191-78.2022.8.26.0453, o expert apresentou laudo (fls. 127/132), que constatou que o acusado Rafael tinha comprometida totalmente sua capacidade de autodeterminação.

Após a homologação do laudo, as partes apresentaram memoriais escritos. O D. Promotor pugnou pela procedência da ação com substituição da pena corporal pela medida de segurança de internação (fls. 665/672) e a defesa pleiteou a absolvição imprópria com medida de segurança de tratamento ambulatorial (fls. 673/674).

Eis o introito.

Adianto que a pretensão condenatória não procede, ante a situação de inimputabilidade do acusado.

Fundamento.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Passo a análise da prova oral produzida em solo policial.

Felipe Pereira da Silva, acusado e denunciado pelo delito previsto no art. 180 do CP, declarou o seguinte (fl. 21): "nesta data estava em sua residência quando compareceram no local policiais civis lhe indagando a respeito de um televisor da marca LG de 40 polegadas, supostamente proveniente de furto; Que o declarante confirmou aos policiais que de fato havia instalado na sala de sua casa um televisor com as mesmas características, sendo certo que autorizou os policiais a entrarem em seu imóvel a apreenderem referido aparelho para fins de investigação; Que o declarante comprou a TV em questão pela quantia de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) da pessoa de Rafael, filho da Nelci; Que esclarece que há alguns dias atrás, não sabendo precisar a data, Rafael passou durante a madrugada em sua casa, oferecendo a respectiva televisão para venda, dizendo que precisava do dinheiro para comprar drogas, ocasião em que o declarante comprou pela quantia acima mencionada; Que o declarante alega que não tinha conhecimento de que tal televisor pudesse ser produto de furto; Que, porém, ao ser indagado pela Autoridade Policial, confirma que já conhecida anteriormente Rafael e tem conhecimento de que o mesmo é usuário de drogas e já foi preso pela prática de furto". O feito foi desmembrado em relação a Felipe por estar beneficiado pela suspensão condicional do processo. Seu relato em solo policial apenas servirá para análise quanto à materialidade do crime de furto, em tese cometido por Rafael.

Juliana Aparecida Moraes de Souza, vítima, relatou o seguinte (fl. 30): "no último sábado, 16/10/2021, durante a madrugada, indivíduos desconhecidos pularam o muro e adentraram ao quintal de sua residência, ocasião em que subtraíram na edícula localizada nos fundos do imóvel 01 (um) televisor de 40 polegadas da marca LG, 01 (um) botijão de gás, roupas diversas e em quantidade indeterminada que se encontravam no varal, 01 (um) lençol de casal de cor rosa, toalhas de banho em quantidade indeterminada que se encontravam estendidas no varal e dentro de um armário, bem como quantidade indeterminada de produtos de limpeza e de produtos de higiene para cães que se encontravam em um armário na lavanderia; Que a declarante somente notou o furto após acordar pela manhã, não tendo suspeitos a indicar; Que não houve arrombamento e na residência não possui câmeras de segurança; Que acionou a Polícia Militar e registrou a ocorrência; Que na data de hoje, 22/10/2021, policiais civis entraram em contato com a declarante informando sobre a localização de um televisor com as mesmas características do seu que fora subtraído; Que a declarante compareceu nesta Delegacia de Polícia e ao ver o televisor apreendido o reconheceu com total certeza como sendo de sua propriedade e que fora subtraído na madrugada do dia 16/10/2021; Que neste ato recebe referido televisor mediante auto de entrega; Que não conhece as pessoas de Felipe e Rafael".

Marcelo Bariotto Evangelista, policial civil, testemunha da acusação, declarou o seguinte (fl. 31): "Informa o depoente que é policial civil com exercício nesta delegacia de polícia e que na data dos fatos recebeu denúncia de que na residência de Felipe Pereira da Silva, vulgo "Xurupita" havia um Televisor da marca LG de 40 polegadas que seria proveniente de furto. Sendo assim, diligenciou junto com seu colega policial civil Evandro até a residência do investigado, localizada na Rua Catanduva, 213 - Vila Abel, neste município, onde, em contato Felipe, este logo confessou que de fato havia um televisor com as mesmas características da denúncia, o qual estava instalado na sala de sua casa e, então, autorizou os policiais a adentrarem no imóvel e a apreenderem referido aparelho; Que Felipe alegou que havia adquirido recentemente tal televisor, pela quantia de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), da pessoa de Rafael, filho da Nelci, afirmando ainda que não tinha conhecimento de que o objeto em questão poderia ser produto de furto. Com isso o respectivo televisor foi devidamente apreendido em auto próprio para fins de investigação quanto a sua procedência, sendo o Felipe ouvido em declarações e em seguida liberado".

Evandro Aparecido Mesquita, policial civil e testemunha da acusação, corroborou com o depoimento de seu colega Marcelo (fl. 32).

Ana Cláudia Clemente Ferreira, policial militar e testemunha da acusação, declarou o seguinte (fl. 33): "Informa a depoente que é policial militar com exercício nesta cidade de Pirajuí e que na data dos fatos estava exercendo suas funções no atendimento ao público na base da cia polícia militar deste município; Que no dia

16/10/2021 compareceu na respectiva base da polícia militar a vítima Juliana Aparecida Moraes de Souza comunicando que possui uma residência localizada na Rua Higino Marangom, 203 - Centro, deste município e que haviam adentraram no quintal da sua residência e subtraído de dentro de um quarto da edícula 01 (um) televisor LG de 40 polegadas e na área externa 01 (um) botijão de gás, roupas do varal, um lençol de casal cor de rosa, varias toalhas de banho estendidas no varal e outras no armário dentro do banheiro e produtos de limpeza e produtos de higiene dos cachorros que estavam guardados em um armário que ficava na lavanderia, não sabendo informar quem foi o autor; Que diante disso foi entregue um Token para à vítima, bem como a mesma foi orientada a comparecer nesta delegacia para confecção do BOPC".

Rafael Soares de Souza, acusado, ao ser interrogado disse o seguinte (fl. 34): "Que confessa que praticou o furto na residência da vítima Juliana, durante a madrugada do dia 16/10/2021; Que naquela ocasião o interrogando estava em companhia de ARTHUR, que também participou do furto; Que ARTHUR mora na Vila Ortiz e é irmão de MARCOS VINÍCIUS; Que esclarece para adentrarem no imóvel, o interrogando e ARTHUR pularam o muro da residência; Que, porém, não danificaram nenhuma porta ou janela para entrar, pois a porta dos fundos estava aberta; Que o interrogando subtraiu do local uma TV de 40 polegadas; Que posteriormente, ainda de madrugada, o interrogando até a residência da pessoa que conhece como XURUPITA, na Vila Abel, e negociou a TV com ele; Que o interrogando vendeu a TV para XURUPITA em troca de drogas; Que esclarece que XURUPITA lhe entregou 13 (treze) pedras de crack, em troca da TV, as quais o interrogando posteriormente consumiu; Que ARTHUR subtraiu alguns objetos, sendo 01 (um) botijão de gás, produtos de limpeza, toalhas de banho e diversas roupas, todavia, o interrogando não sabe dizer o que ARTHUR fez com tais objetos, pois ficaram em poder dele; Que, por fim, o interrogando informa que é usuário de crack e já foi preso anteriormente pela prática de crimes de furto; Que o interrogando saiu da prisão no mês de Maio deste ano para cumprir pena em Regime Aberto, quando retomou o uso de crack e voltou a praticar furtos na cidade".

Na fase policial, Artur não foi ouvido.

Analisando os depoimentos prestados em juízo:

Juliana Aparecida Moraes de Souza, vítima, relatou que no sábado pela manhã, por volta de 6h, a mãe da depoente acordou e foi até a lavanderia, onde viu tudo bagunçado e todas as portas do armário estavam abertas. A depoente foi chamada. Notaram a ausência de algumas roupas no varal e produtos de limpeza, bem como do cachorro da casa. Na edícula, notaram a falta do televisor. Na noite anterior, os bens estavam na residência, inclusive, na parte da madrugada chovia muito e por volta de 1h da manhã, sua mãe foi ao lado de fora da casa para averiguar se houve algum problema com a calha nova que teria instalado e até aquele momento, não houve nenhum problema na casa. Não houve arrombamento na casa. Tudo indica que os réus pularam o muro, pois havia objetos da depoente na casa do vizinho, como uma lata de tinta. Na época havia cerca elétrica, mas não estava funcionando. O muro da casa é bem alto e a frente é bem alta. A televisão foi recuperada cerca de dez dias depois. Não sabe dizer qual o prejuízo, pois foram vários produtos, mas de valores baixos, tais como materiais de limpeza, botijão de gás e roupa, não sabendo precisar o valor exato. Em decorrência do delito, ficou abalada psicologicamente, com medo que alguém entrasse na casa. Tanto que colocaram uma cerca. Não procurou atendimento psicológico. Mas a mãe ficou sem dormir, por estar com medo. A polícia informou quem havia comprado a televisão, pessoa que não se recorda o nome, conhecida como Xurupita.

Evandro Aparecido Mesquita, policial civil e testemunha da acusação informou que tomaram conhecimento dos fatos. Após, tomaram conhecimento que a televisão estava na casa de Xurupita. Ele admitiu que a TV estava no local e disse que comprara de Rafael, por R\$ 130,00. Xurupita disse que tinha conhecimento que Rafael estava praticando furto. Localizaram Rafael, que admitiu ter praticado o furto junto com Artur. Tem conhecimento que a pedra de crack custa em torno de R\$ 10,00. Rafael é conhecido como usuário de drogas e como furtador, havendo vários procedimentos na Delegacia por conta de furtos. Localizaram Rafael nos fundos da casa do pai dele. A mãe de Rafael mudou-se para Avaí. Era comum encontrar Rafael em biqueiras. Rafael

confessou o delito, que teria praticado junto com Artur. Rafael disse que trocou a televisão com Felipe, por treze pedras de "crack".

Ana Cláudia Clemente Ferreira, policial militar e testemunha da acusação, declarou que atendeu a vítima, logo após a subtração. Não teve participação na localização dos bens subtraídos ou com Rafael e Artur.

Marcelo Bariotto Evangelista, policial civil, testemunha da acusação, declarou que no dia 22 de outubro, o policial Evandro recebeu uma ligação de que na casa de Felipe, vulgo "Xurupita", havia produtos de furto. Foram até a casa e perguntaram para Felipe sobre o televisor. Felipe admitiu que estava com o televisor, que havia comprado de Rafael, durante a madrugada. Felipe autorizou a entrada dos policiais e localizaram o televisor na casa. Felipe disse que comprou o televisor de Rafael, pelo valor de R\$ 130,00. Conhece Rafael e Artur, que já estiveram várias vezes na Delegacia. Tem notícia que Rafael é usuário de droga. Ele não tem residência fixa, antes morava com a mãe. Encontraram Rafael nos fundos da casa do pai.

Interrogado em Juízo, o réu Rafael Soares de Souza disse que são verdadeiros os fatos. Subtraiu os bens para trocar por droga. Pulou o muro para adentrar no local. Disse que o muro não era muito alto, mais ao menos do seu tamanho. Não estava junto com Artur. É morador de rua desde os vinte e dois anos de idade. É usuário de drogas e já esteve internado duas vezes, ficando apenas um mês internado, o que não foi suficiente. Praticou o furto sozinho. Disse que foram o delegado e os policiais que o ameaçaram e disseram para falar de colocar o Artur no delito furto.

Artur Soares de Oliveira Neto, acusado, ao ser interrogado, negou a conduta delitiva. Não participou do furto com Rafael. Acredita que foi imputada a ele esse delito por conta de ter saído há pouco tempo da prisão. Não foi interrogado na fase policial. No dia dos fatos, estava na casa da sua mãe, pois no dia seguinte iria viajar para a casa de seu padrasto.

Pois bem.

A materialidade delitiva resultou provada pela instauração do Inquérito (fls. 2/3), boletins de ocorrência (fls. 4/5 e 19/20), laudo do local do crime (fls. 11/18), relatórios de informação (fl. 22, 36, 37), auto de reconhecimento de objeto (fl. 23), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 24/28), auto de avaliação (fl. 29), relatório final (fls. 174/178), bem como pela prova oral colhida.

Primeiramente, cumpre ressaltar a importância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais. Neste sentido: "Como é cediço, as palavras das vítimas, evidentemente, merecem crédito, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexistente motivo para infundada incriminação a inocente". (TJSP; Apelação Criminal 0001883-64.2016.8.26.0537; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020).

Por ter sido um dos denunciados encontrado na posse de um dos objetos furtados objeto, por si só, já faz presumir-se autoria de delito patrimonial, cabendo aos próprios acusados a tarefa de afastar tal presunção. Nesse sentido: "RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada à posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento do policial - validade, só devendo o depoimento do policial ser visto com reservas, quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. DOLUS - demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior - elementos externos utilizados para a comprovação do animo do agente. PENA - primeira fase - base fixada acima do mínimo legal - maus antecedentes - segunda fase - presente a agravante da reincidência - redução da fração - terceira fase - pena inalterada - ausentes outras causas modificadoras de pena. REGIME - réu que é reincidente - indicação de que penas anteriores não atingiram a finalidade preventiva específica - o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) - regime semiaberto -

necessidade. SUBSTITUIÇÃO - impossibilidade - réu reincidente em crime doloso - regime - semiaberto - manutenção, ausente recurso ministerial - provimento parcial ao recurso, com determinação. (TJSP; Apelação Criminal 0001533-79.2017.8.26.0266; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 12/09/2019; Data de Registro: 13/09/2019)" Ainda, os policiais que participaram das diligências, tanto em solo policial, quanto em juízo, narraram de forma harmônica e coerente o envolvimento do acusado com o ilícito cometido, como pode ser observado dos depoimentos acima transcritos. No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho. Ademais, nos casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase sempre impossível, deve ser conferido às declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal". (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).

Vale ressaltar, outrossim, que nada de concreto foi trazido pela defesa que afastasse a credibilidade dos depoimentos dos policiais.

Em outras palavras, a versão trazida pelos policiais foi firme, coesa, mantendo-se íntegra desde a fase policial, além de ser corroborada com os elementos materiais apresentados, não tendo sido apresentada qualquer razão para que se possa desacreditar a narrativa dos policiais.

Do mesmo modo, devidamente consumado o delito, uma vez que o objeto saiu da esfera de proteção da vítima, sendo que o acusado passou a ter posse mansa e pacífica.

Neste sentido, segundo recurso (REsp 1.524.450), sob a relatoria do ministro Nefi Cordeiro, foi definida a seguinte tese: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

Não é possível aplicar o princípio da insignificância neste caso, uma vez os bens furtados não possuem valor ínfimo, conforme auto de avaliação, considerando ainda a recalcitrância do acusado em cometer crimes contra o patrimônio. Senão vejamos a jurisprudência do STF:

15/03/2016 - SEGUNDA TURMA - HABEAS CORPUS 133.252 - MINAS GERAIS RELATORA: MIN. CÂRMEN LÚCIA PACTE.(S) :FELIPE DAS GRAÇAS PEREIRA ANDRADE IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL COATOR(A/S) (ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R\$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas

irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal. 4. Ordem denegada. - grifo nosso.

Entretanto, o perito judicial não conseguiu constatar a ocorrência da escalada pois, "no momento da realização dos exames, os danos decorrentes da prática criminosa já haviam sido restaurados, considerando o estado de preservação do local prejudicado". No entanto, referida qualificadora restou comprovada pela prova oral, nos termos do art. 167 do CPP, tanto pelas informações prestadas pela vítima e pela confissão do acusado. O STJ entende que caso demonstradas inequivocamente as circunstâncias pelo conjunto probatório nos autos, a perícia específica é desnecessária:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. COMPROVAÇÃO. PROVA INCONTESTE. 1. Não se olvida que esta Corte firmou orientação de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. Precedente. 2. Contudo, importa ressaltar a orientação de que, "excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...] "(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 30/9/2021). 3. Na hipótese, a circunstância qualificadora foi comprovada pela prova oral, inclusive pela confissão do próprio réu, além da existência de laudo papiloscópico "que identificou impressões digitais no local apontado pela vítima como sendo o local onde o réu pulou o muro". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp n. 1.895.487/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP). PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE ROBUSTO COTEÚDO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consignado no decisum agravado, em situações excepcionais, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 663.991/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 12/5/2022.).

Desta feita, comprovado o furto na forma qualificada, pela escalada (§4º, II). De outra banda, não restou comprovada a qualificadora de concurso de agentes. Isto porque a única evidência da participação do Artur era o depoimento de Rafael na fase policial. Mas em juízo, nem a vítima e nem as testemunhas prestaram informações sobre a participação de Artur no delito. Em seu interrogatório judicial, não confirmou a participação de Artur. Não há elementos que corroborem o concurso de agentes. Por tal razão afasto a qualificadora.

Cumprе consignar que a acusação feita por Rafael aos policiais não é corroborada por nenhum elemento de prova, motivo pelo qual deixo de acolhê-la.

Por tais razões, a materialidade do delito é inequívoca.

Entretanto, a autoria de crime não pode ser imputada ao réu, considerando sua situação de inimputabilidade. Em que pese a materialidade bem definida pelo conjunto probatório, como alhures mencionado, e a manifestação do D. Promotor em

sede de alegações finais, a inimizabilidade do acusado é patente e se sobrepõe, por prejudicar o elemento volitivo do acusado. Não há dolo.

Data máxima venia ao entendimento da D. Promotoria, a hipótese não é de semimizabilidade e sim de inimizabilidade total, nos termos do artigo 26, caput, do CP. In verbis: "É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento" - destaque nosso.

Neste sentido, o laudo pericial acostado no incidente 0000191-78.2022.8.26.0453 (fls. 127/132) apresentou as seguintes conclusões: "O réu Rafael Soares de Souza era ao tempo da ação, portador de Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência (19.2) e Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - intoxicação aguda (F 19.0), condições essas que não prejudicavam sua capacidade de entendimento, mas prejudicava totalmente sua capacidade de determinação, considerando o delito cometido. Sugerimos tratamento psiquiátrico preferencialmente em CAPS AD, com equipe multidisciplinar por um período mínimo de dois anos" - destaque nosso. Assim, o efeito do reconhecimento de sua inimizabilidade é a isenção da pena e a aplicação de medida de segurança, devendo o acusado ser absolvido, pois a inimizabilidade é causa de exclusão da culpabilidade, sendo a medida de segurança sanção penal, porém de caráter preventivo (Código Penal Comentado, Delmanto, 5ª ed. Renovar, 2000, p.50 e p. 168).

Destarte, em que pese o pedido da defesa em alegações finais (tratamento ambulatorial), merece acolhimento o pedido de aplicação de medida de segurança de internação, conforme sugerido pelo expert - pelo prazo mínimo de dois anos, devendo ser reavaliada, nos termos dos artigos 97 e respectivos parágrafos, do Código Penal. Ainda há que consignar que o fato punível como crime prevê pena de reclusão, o que afasta o tratamento ambulatorial.

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e ABSOLVO IMPROPRIAMENTE o réu RAFAEL SOARES DE SOUZA da acusação da prática do delito previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 96, inciso I, c.c. 97, ambos do Código Penal, imponho-lhe a aplicação da MEDIDA DE SEGURANÇA, consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico (ou estabelecimento estatal adequado e similar), pelo prazo indeterminado, fixando o prazo de 2 (dois) anos para a realização da nova perícia, nos termos do art. 97, § 1º, do Código Penal, perdurando enquanto não averiguada por perícia médica a cessação da periculosidade, observada soma dos limites máximos das penas privativas de liberdade abstratamente cominadas aos delitos praticados, conforme apregoa a Súmula nº 527 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme a determinação do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes o *fumus commissi delicti*, que decorre da própria fundamentação acima exposta em que se reconhece a conduta do réu, embora inimizável; o *periculum libertatis* que, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto dos crimes praticados pelo réu e do risco concreto de ele voltar a delinquir, substituo a prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória (artigo 319, VII, do CPP). Expeça-se, portanto, a guia provisória.

Expeça-se o necessário para a imediata transferência do sentenciado ao nosocômio judicial, encaminhando-a à unidade prisional onde o denunciado está recolhido.

Expeça-se Guia para acompanhamento da medida de segurança ora imposta e arquivem-se os autos com as comunicações de estilo.

P.I.C.

Pirajuí, 27 de outubro de 2022.

Assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita